공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2020 - 252 호 2020. 8. 24.

사 건 번 호 2017서경3050

사 건 명 한국마이크로소프트 유한회사의 거래거절행위에 대한 건

피 심 인 한국마이크로소프트 유한회사
서울 종로구 종로1길 50, 에이동 12층
대표이사 이○○
대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 윤○○, 성○○, 김○○

심의종결일 2020. 7. 17.

주 문

피심인 한국마이크로소프트 유한회사는 각 시·도 교육청이 발주하는 업무용 표준오피스 소프트웨어 연간사용권 구매 입찰에서 피심인의 업무용 표준오피스 소프트웨어 연간사용권을 공급받아야만 입찰계약을 이행할 수 있는 거래상대방에 대하여 부당하게 공급자증명원 등 관련 서류의 발급을 거절하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 한국마이크로소프트 유한회사(이하 '한국마이크로소프트')는 개인용 컴퓨터 및 서버 운영체제, 업무용 프로그램[1] 등의 소프트웨어를 개발, 제작 및 판매하는 자로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 아래의 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(매년 6월 30일 기준, 단위: 백만 원)

연도	자산총액	자본금	매출액	영업이익	당 기 순이익	설립일
2016	570,004	300	713,211	112,568	104,104	1988.9.16.
2017	645,653	300	797,259	△133,319	84,129	
2018	689,603	300	892,488	41,858	37,142	

※ 자료출처: 피심인 제출자료

나. 시장 구조 및 실태

1) 소프트웨어 라이선스의 정의

3 소프트웨어산업진흥법 제2조 제1호에 따르면 소프트웨어란 컴퓨터, 통신, 자동화 등의 장비와 그 주변장치에 대하여 명령・제어・입력・처리・저장・출력・상호작용이 가능하게 하는 지시・명령(음성이나 영상정보 등을 포함한다)의 집합과 이를 작성하기 위하여 사용된 기술서(記述書)나 그 밖의 관련 자료를 말한다.

4 이러한 소프트웨어는 저작권법에 의해 저작권자의 권리가 보호된다. 저작권법

1) '오피스(office) 소프트웨어'라고 지칭하기도 한다.
2) 2017. 4. 18. 법률 제14813호로 개정된 것을 말한다.

제2조 제16호에 따르면 '컴퓨터프로그램저작물'이란 특정한 결과를 얻기 위하여 컴퓨터 등 정보처리능력을 가진 장치 내에서 직접 또는 간접으로 사용되는 일련의 지시·명령으로 표현된 창작물로, 소프트웨어는 이러한 컴퓨터프로그램저작물에 해당한다. 컴퓨터프로그램저작물은 저작권법 제4조 제1항 제9호에 따라 저작물의 한 종류로서 저작권법에 의해 보호되고 있다.

5 저작권자는 저작권법 제46조에 따라 다른 사람에게 그 저작물의 이용을 허락할 수 있고, 허락을 받은 자는 허락받은 이용 방법 및 조건의 범위 안에서 그 저작물을 이용할 수 있다. 또한 허락에 의하여 저작물을 이용할 수 있는 권리는 저작권자의 동의 없이 제3자에게 이를 양도할 수 없다. 이와 같은 권리를 통상 '라이선스(License)'라고 한다.[3)]

2) 교육기관 업무용 소프트웨어 라이선스 시장 현황

가) 교육기관의 분류

6 일반적으로 업무용 소프트웨어를 구매하는 교육기관은 ① 17개 시·도 교육청과 관할 초·중·고등학교, ② 대학교, ③ 유치원과 어린이집, ④ 학원과 기타 공공기관으로 나눌 수 있다. 이하에서는 이 사건 입찰의 발주기관인 시·도 교육청을 위주로 살펴보기로 한다.

나) 주요 제품 현황

7 교육기관에서 주로 사용하는 제품으로는 업무용 소프트웨어 제품, 그 외 운영체제 소프트웨어 제품, 서버 소프트웨어 제품, 백신 소프트웨어 제품, pdf 소프트웨어 제품 등이 있다.

8 업무용 소프트웨어 제품의 경우 주식회사 A사(이하 'A사')와 한국마이크로소

3) 이 사건 입찰에서는 '사용권'이라는 명칭으로 지칭된다.

프트, 주식회사 B사(이하 'B사')가 제조한 소프트웨어가 있다. A사 제품으로는 '●●', '▲▲', '■■'가, 한국마이크로소프트 제품으로는 '워드', '엑셀', '파워포인트'가, B사 제품으로는 '★★★', '▼▼▼', '▶▶▶'가 사용된다.

9 위 소프트웨어 중 각 시·도 교육청과 관할 초·중·고등학교에서는 문서 작성의 경우 A사의 ●●을, 계산 및 발표용 제품은 한국마이크로소프트의 엑셀과 파워포인트를 대부분 사용하고 있다. 이는 교육기관 내부의 업무시스템과의 호환성과 관련이 있는 것으로, 각 시·도 교육청 및 학교의 업무처리의 모든 과정을 전자적으로 관리하는 업무관리시스템은 ●●[4]을, 교육청 및 학교의 예산 편성, 지출, 계약, 결산 등 재정·회계업무를 전자적으로 관리하는 에듀파인시스템은 엑셀을 표준으로 지원하고 있고 타 프로그램과는 호환성이 낮다.

다) 시장 규모

10 17개 시·도 교육청이 구매하는 교육기관용 업무용 소프트웨어 라이선스는 조달청 나라장터시스템을 통해 구매되는바, 각 입찰들의 낙찰가를 토대로 시장규모를 살펴보면 2016년 약 443억 원, 2017년 약 490억 원 수준의 시장으로 추정된다. 위 매출액은 A사와 한국마이크로소프트가 제조한 제품으로 양분되며 그 외의 제품은 없다.[5]

11 구체적으로 살펴보면, A사 제품 단독 구매는 2016년 약 135억 원, 2017년 약 186억 원으로 점유율은 2016년 30%, 2017년 38%에 해당한다. 한국마이크로소프트 제품 단독 구매는 2016년 약 252억 원, 2017년 약 273억 원으로 점유율은 2016년 약 57%, 2017년 약 56%이다. 그 밖에 A사와 한국마이크로소프트의 제품을 통합하여 구매하는 입찰이 있는데, 이를 통한 구매 규모는 2016년 약 56억 원, 2017년 약 32억 원으로 점유율은 2016년 13%, 2017년 6%이다.

---

4) B사의 ★★★도 교육청 및 학교의 업무관리시스템에서 사용할 수 있는 것으로 확인된다.
5) 한국마이크로소프트 제품의 경우 일부 입찰에서는 업무용 소프트웨어 외에 운영체제, 서버 소프트웨어의 구입 금액이 포함되어있다.

라) 유통경로

12 대부분의 소프트웨어 제조사는 유통에서의 효율성, 비용 등을 고려하여 자체 조직을 갖추기보단 총판과의 계약을 통해 공급하고 있다. 총판은 소비자의 소재지, 규모 및 업종에 따라 여러 대리점들과 계약을 하여 유통한다. 이에 따라 유통 경로는 대체로 아래 <표 2>에서와 같이 소프트웨어 제조사[6] → 총판[7] → 공인파트너 → 소비자의 과정을 통해 공급된다. 공인파트너들은 일반파트너들에게 다시 유통하여 소비자에게 공급되기도 한다.[8]

<표 2> 교육기관용 소프트웨어 라이선스의 일반적 유통 경로

1단계		2단계		3단계		4단계 (생략 가능)		5단계
소프트웨어 제조사	→	총판	→	공인파트너	→	일반파트너	→	소비자

13 17개 시·도 교육청에 대한 업무용 소프트웨어 라이선스의 공급은 입찰에 의하여 이루어지는데, 이 경우에도 위와 같은 유통 경로를 통해 공급된다. 즉, 공인파트너인 대리점이나 일반파트너인 대리점이 낙찰을 받은 후 제조사, 총판을 거쳐 대리점을 통해 교육청에 공급된다. 각 제조사의 내부 정책상 위 유통단계를 두고 있는 점, 입찰공고 상 소프트웨어 제조사의 입찰참가가 제한되는 점, 낙찰자 결정방법인 적격심사제도의 평가기준에서 물품납품 이행실적을 제한하는 점 등의 이유로 인하여 사실상 대리점들만 입찰에 참가하고 있다.

마) 교육기관 업무용 소프트웨어 라이선스 종류

6) 소프트웨어 라이선스 제조사는 유통업계에서 '개발사', '제조사' 혹은 '벤더사'라고 불리며, 이하에서는 '제조사'로 지칭하기로 한다.
7) 이 사건 입찰의 경우 한국마이크로소프트 교육기관 부분 총판은 주식회사 C사 및 주식회사 D사가, A사 교육기관 부분 총판은 주식회사 E사가, B사 교육기관 부분 총판은 주식회사 F사가 맡고 있었다(이하 총판 명칭을 언급함에 있어 '주식회사'는 생략한다).
8) 공인파트너는 제조사의 자체 자격기준을 충족하여 공인파트너자격이 부여된 사업자를 의미한다. 일반파트너는 공인파트너자격이 부여되지 않은 사업자이다. 이들은 통상 '리셀러', '대리점'이라고 불리며, 이하에서는 '대리점'으로 지칭하기로 한다.

14 주요 제조사의 교육기관 업무용 소프트웨어 라이선스의 종류는 아래 <표 3>과 같다.

<표 3> 한국마이크로소프트 및 A사의 교육기관 업무용 라이선스 종류

제조사	사용구분	종류	설명
한국 마이크로 소프트	영구버전	Open License	최초 5개 이상의 제품을 저렴한 가격으로 구입하고자 하는 경우에 사용
	연간계약 (OVS-ES)	Campus Agreement (CA)	연 단위의 Subscription(정기구독) 형태로 기관 전체의 PC를 표준화하려는 대학교(대학원, 대학병원 포함)에서 사용
		School Agreement (SA)	연 단위의 Subscription(정기구독) 형태로 구매 행정의 편의성 확보를 원하는 교육청 및 산하기관에서 사용
A사			

15 이 중 각 시·도 교육청은 영구 라이선스가 아닌 연간 라이선스를 주로 구매하므로 한국마이크소프트 제품의 경우 OVS-ES를, A사의 경우 ☆☆☆를 구매하게 된다. 이 사건 입찰에서도 수요기관은 한국마이크로소프트의 제품은 OVS-ES를, A사의 제품은 ☆☆☆를 구매하였다.

16 한편 제조사의 판매제품은 이러한 볼륨 라이선스 방식으로 어떤 업무용 소프트웨어들을 판매할지에 따라 여러 제품이 구성된다. 예를 들어 워드, 엑셀, 파워포인트 등의 소프트웨어로 구성된 OVS-ES도 있고, 운영체제(Windows)와 서버(Cal)까지 포함된 OVS-ES도 있다. A사의 경우 ●●을 주요 구성품으로 하는 ▽▽▽가 있고, ●●, ▲▲, ■■ 등으로 구성된 ◇◇◇도 있다.

3) 입찰제도 개관

가) 적격심사제

17 적격심사제란 국고의 부담이 되는 경쟁 입찰에 있어서 예정가격 이하, 최저가격으로 입찰한 자의 순서대로 해당 계약이행능력을 심사하여 낙찰자를 결정하는 방법을 말한다.[9] 계약이행능력심사 평가 항목에는 입찰자의 이행실적, 기술능력, 재무상태, 과거 계약이행 성실도 등이 포함된다. 입찰 절차는 개찰 결과 예정가격 이하이면서 최저가격으로 입찰한 자 순으로 적격심사를 실시하여 적격심사 항목의 총점이 기준 점수 이상일 경우 낙찰자로 선정하는 방식으로 이루어진다.

나) 적격심사 세부기준의 내용

18 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」에 따라 물품납품 이행능력과 입찰가격을 합하여 만점이 되며, 신인도와 결격사유의 존부에 따라 종합점수가 가감된다. 투찰 결과 예정가격 이하로서 최저가격 입찰자 순으로 우선순위를 부여한 다음 적격심사를 실시하고, 종합점수가 85점 이상일 경우 최종 낙찰자로 결정한다. 이때 후순위 입찰자의 종합점수가 선순위 입찰자의 종합점수보다 높다 하더라도 선순위 입찰자의 종합점수가 85점 이상인 경우 적격심사를 통과하여 최종 낙찰자로 결정됨에 따라 후순위 입찰자의 적격심사는 이루어지지 않으며 낙찰에서 배제된다.

4) 이 사건 입찰 현황

가) 입찰 개요

19 「2018년 업무용 소프트웨어 표준 오피스 소프트웨어 연간사용권 구매」 입찰[10]은 경상북도교육청 및 그 소속 전 기관에서 2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지 1년간 업무용으로 사용할 소프트웨어 라이선스를 구매하는 사업으로, 낙찰자 결정방법을 적격심사제로 하여 2017년 10월 공고되었다.

9) 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조
10) 이하 '이 사건 입찰'이라 한다.

20 이 사건 입찰은 적격심사 우선순위자가 될 경우 아래 <표 4>에서와 같이 제조사의 공인인증파트너를 증명할 수 있는 인증서와 공급증명원[11]을 발주처에 제출하여야 하는 조건을 두고 있으며, 미제출 시에는 해당 우선순위자는 부적격 처리되어 배제되고 후순위자가 적격심사 대상자가 된다. 따라서 적격심사 1순위 대상자가 된 사업자는 제조사로부터 <표 4>의 서류를 발급받아야 하며, 발급 받지 못할 경우에는 발주처와 정상적으로 계약을 체결할 수 없게 된다.

<표 4> 이 사건 입찰 규격서 발췌

Ⅲ 특수조건
1. 계약 시 제조사의 공인인증파트너를 증명할 수 있는 인증서 및 공급증명원을 제출한다.

나) 이 사건 입찰의 특징

21 이 사건 입찰 이전에는 각 교육청이 주로 수의계약 방식으로 한국마이크로소프트 또는 A사와 소프트웨어 라이선스 구매계약을 체결하였다. 그러나 2015. 10. 22. 감사원 감사에 따라 각 교육청은 제조사 간 경쟁계약을 실시할 필요가 발생하게 되었고, 이 사건 입찰에서도 이러한 취지를 반영하여 입찰 구매사양이 변경되었다.

11) 소프트웨어 개발사가 정품을 공급할 수 있다는 것을 확인하는 문서로서 통상 계약담당공무원이 제조사 혹은 낙찰자에게 제출할 것을 입찰규격서 등에 명시한다.

「정부 입찰·계약 집행기준」(기획재정부계약예규 제318호, 2016.12.30. 일부개정) 제5조의3

② 제1항제2호에 따른 물품구매에 있어 특수한 성능 등을 규격서(시방서)에 반영하고자 하는 경우에는 규격서 작성단계에서 계약담당공무원은 별지 제3호의 예시를 참조하여 입찰공고전에 제조사 또는 기술지원사(이하 '제조사 등'이라 한다)와 물품공급 또는 기술지원협약을 체결하여야 한다. 다만, 물품공급 또는 기술지원협약이 이루어지지 않은 경우에는 다른 물품으로 발주할 수 있다.

③ 계약담당공무원은 제2항에 의한 협약내용을 입찰공고에 명시하여야 하며, 낙찰자 결정 후 낙찰자에게 그 사본을 제공하여 낙찰자가 제조사 등으로부터 물품공급 또는 기술지원확약서를 발급받을 수 있도록 하여야 한다.

<표 5> 감사원 통보('15.10.22.) 중 발췌

조치할 사항 교육부 장관은 ① 앞으로 각 교육청에서 ㄱ 라이선스 중 필요하지 않은 라이선스를 구매하지 않도록 지도·감독하고 ② 프로그램을 구매할 때 일반 입찰이 가능한 라이선스에 대해서는 경쟁계약을 추진하도록 유도하는 방안을 마련하시기 바랍니다.

※ 자료출처: 감사원 누리집

22 그 결과 이 사건 입찰에서는 A사와 한국마이크로소프트의 제품 외에 그간 구매 대상이 아니었던 B사의 ★★★도 공급 가능한 대상이 되었다.

<표 6> 이 사건 입찰 공고문 발췌

23 구체적으로는 위 <표 6>에서와 같이 A사는 다른 소프트웨어 라이선스와 함께 공급할 수도 있고 A사 제품만으로[12] 공급할 수도 있다. 그러나 한국마이크로소프트와 B사는 반드시 다른 소프트웨어 라이선스와 함께 공급하여야 한다.[13] 즉, 한국마이크로소프트의 OVS-ES는 A사의 ▽▽▽나 B사의 ★★★ 중 하나와 조합하여 공급할 수 있고, B사는 OVS-ES만 조합하여 공급을 할 수 있다.

2. 위법성 판단

12) A사오피스☆☆☆로 공급

13) 공고문 내용에 따르면 한국마이크로소프트 OVS-ES로 공급할 경우 교육청 내부 업무시스템과 연동이 가능한 워드프로세서 소프트웨어를 추가로 납품해야 한다고 규정했기 때문이다. B사의 ★★★는 연동이 되는 것으로 확인된다.

가. 인정사실 및 근거

1) 인정사실

가) 피심인과 B사 및 A사 간의 협의

24 피심인은 이 사건 입찰에 배정된 예산이 직전 입찰 대비 약 50% 삭감된 반면 입찰 규격 특성상 피심인의 제품만으로는 단독 공급이 불가능하였기 때문에 사전에 타 제조사와 이 사건 입찰에서 대리점에게 공급할 제품 조합 및 단가에 대해 협의할 필요가 있었다. 이에 피심인은 B사 및 A사와의 협의를 시도하였다.

25 최초에는 B사 및 그 총판 F사와 협의를 시도하였으나, B사 측과 공급수량[14] 및 공급가격 등의 요구조건이 상이하여 협의가 원활하게 이루어지지 않았다.

<표 7> 2019.1.30. C사 직원(진○○ 이사) 진술조서 발췌

문) 이 사건 입찰과 관련하여 MS[15]나 총판인 C사 차원에서 B사, A사와 협의할 필요성이 있었나요?
답) 네, 경북교육청의 예산 자체가 충분하지 않았습니다. MS오피스의 공급수량(FTE) 및 총판 공급가를 정하기 위해서는 사전에 B사나 A사와 협의해볼 필요가 있었습니다. … (생략) … 이 사건 입찰은 MS오피스와 A사 오피스가 통합 발주되었으나 예산은 그만큼 늘지 않아 공급가를 맞추는 것이 상당히 빠듯했습니다.
문) B사 측과는 어떤 협의가 있었나요?
답) MS는 자신의 공급수량 32,000FTE를 조정해줄 생각이 없다고 선을 그었고 C사와 B사가 서로 공급단가를 협의해야 한다고 했습니다. … (생략) … 그런데 B사 측에서 ★★★에 대한 공급금액을 너무 높게 보장해달라고 요구하는 바람에 옥신각신 했던 것으로 기억합니다.

14) 피심인은 필요한 공급수량(Full Time Equivalent, FTE)을 제품 사용 인원을 기준으로 산정한다. 통상 '교육관련기관의 정보공개에 관한 특례법'에 따라 학교가 공시하는 자료에 근거하여 '정규교원(Full-time Faculty) + 비정규교원(Part-time Faculty) 1/3 + 정규직원(Full-time Staff) + 비정규직원(Part-time Staff) 1/2'로 산출하나 입찰규격서상 구체적인 FTE가 명시되어 있지 않거나 수요기관의 이의가 있는 경우는 협의된 수량을 기초로 산정한다.

15) 한국마이크로소프트를 의미한다. 이하 같다

26 그러던 중 A사 측에서 피심인과 이 사건 입찰에 공급할 제품 조합 및 단가 등에 대해 협의하기 위해 피심인에게 먼저 연락을 취해왔다. A사 측은 자신들의 공급가격을 최대한 낮추겠으니 ●●과 MS오피스의 조합으로 대리점들에게 공급하는 방안을 제안하였다. 피심인은 이러한 제안을 승낙하고 총판에게 해당 사실을 전파하였다.

<표 8> 2018.8.16. 피심인 소속 강○○ 부장 진술조서 발췌

문) 진술인은 이 사건 입찰 이전에 '①MS오피스+★★★' 조합을 위해 B사 또는 그 총판과 협의한 사실이 있나요? 답) … 이 사건 입찰 이전에 B사 측에서 먼저 MS에 접근하여 MS오피스와 ★★★를 조합하여 납품할 것을 제안했습니다. … B사 측에서는 MS의 공급물량(FTE)를 줄여달라고 요구했습니다. 그런 협의가 계속 진행되었습니다. 문) 진술인은 이 사건 입찰 이전에 '②MS오피스+●●' 조합을 위해 A사 또는 그 총판과 협의한 사실이 있나요? 답) B사와 협의가 진행되던 중에 A사 측으로부터 연락을 받아 입찰일 전까지 2차례 만남을 가졌습니다. A사 측에서는 이△△ 이사, 이▽▽ 부장이 나왔고, 첫 번째 만남은 MS 사무실 근처 커피숍에서, 두 번째 만남은 A사 사무실에서 이루어졌습니다. … A사 측에서는 MS오피스+●● 가격을 많이 낮출 수 있다고 제안했습니다. (이하생략) …

<표 9> 2019.2.28. 피심인 소속 강○○ 부장 진술조서 발췌

문) 진술인과 김△△ 이사는 2개 총판(C사, D사)에게 '이번 입찰은 MS+●● 조합으로 가기로 결정했으니 파트너사들에게 전달하라'고 말한 사실이 있나요? 답) 총판인 C사 진○○ 이사, D사 정○○ 부장에게 연락해서 A사에서 획기적으로 낮은 공급가격으로 MS에게 맞춰줄테니 같이 참여하자고 제안했다고 전달했습니다. … (이하 생략) …

나) 주식회사 G사의 입찰 참가

27 주식회사 G사(이하 'G사')는 피심인의 공인파트너 대리점으로서 주로 강원도 소재 교육기관의 업무용 소프트웨어 구매 입찰에 참여하여 피심인 제품을 납품하여 왔으나 A사와는 거래관계가 없는 업체인데, 이 사건 입찰에서 ●●과 MS오피스 조

합으로 제품이 공급될 예정이라는 사실을 알게 되었다.

28 G사는 향후 피심인과 A사와의 장기적인 협력관계가 공고화되어 ★★★ 등 ●●의 대체재가 교육청 입찰시장에서 배제될 경우, 자신과 같이 피심인의 제품만 납품하는 대리점은 낙오될 것을 우려하였다.

29 이에 G사는 이 사건 입찰 참여를 결정하였고, 2017. 10. 20. 최저가로 투찰하여 1순위 적격심사 대상자로 선정되었다. 자세한 입찰 결과는 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 이 사건 입찰 결과

순위	업체명	대표자	투찰금액(원)	투찰률(%)
1	(주)G사	김□□	1,834,900,000	87.24
2	(주)J사	김◎◎	2,048,000,000	97.37
3	(주)F사	양○○	2,065,000,000	98.18
4	(주)G사	조○○	2,087,000,000	99.22
5	(주)H사	서○○	2,090,000,000	99.37

다) 피심인의 공급자증명원 발급 거부

30 피심인과 총판들은 사전에 이 사건 입찰 관련 공급수량 및 공급가격 등 견적을 문의하지 않은 G사가 입찰에 참여하여 1순위로 선정되었음을 인지하였으며, G사가 ●●이 아닌 ★★★를 공급할 계획임을 확인하였다.

<표 11> 2019.2.28. 피심인 소속 강○○ 부장 진술조서 발췌

문) B사와의 협력을 원하지 않고 있던 상황에서, G사가 MS오피스와 ★★★ 조합으로 이 사건 입찰에서 1순위로 선정된 것을 어떻게 알게 되었나요? 답) 총판을 통해 G사가 1순위로 선정되었다는 이야기를 들었습니다. 통상 파트너사가 입찰에 들어올 때는 총판사에 견적을 문의하기 마련인데 G사는 그런 과정이 없었습니다. 그리고 G사가 어떤 제품을 가지고 들어왔는지 묻자 ★★★를 갖고 왔다고 하였습니다.

31 이에 피심인 경상북도 지역 영업담당 강○○ 부장은 G사가 입찰 참여 전 피심인 및 총판과 견적 등에 대해 협의하지 않은 점, 피심인과 A사가 이 사건 입찰에

공급할 제품을 MS오피스와 ●● 조합으로 협의하였고 수요기관도 이러한 제품 조합을 선호함에도 G사는 ●●을 납품할 계획이 없는 점 등을 이유로 G사를 이 사건 입찰에 탈락시킬 의도로 G사의 공급자증명원의 발급 요청을 거절하였다.

<표 12> 2017.10.23. 피심인 소속 강○○ 부장이 작성한 메모

32 입찰에 참가하여 적격심사대상자로 선정된 최저가 입찰자는 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제4장 물품 적격심사 세부기준에 따라, 적격심사신청서 등 관련서류를 제출할 때 공급자증명원을 함께 제출하여야 한다. 이에 따라 G사 김□□ 대표는 2017. 10. 24.부터 2017. 10. 30.까지의 기간 동안 공급자증명원 발급을 위하여 피심인 회사에 직접 찾아가거나 강○○ 부장과의 연락 등을 수차례 시도하였으나, 강○○ 부장은 이에 대응하지 않았다.

33 G사와 거래하는 피심인 총판인 C사의 진○○ 이사는 강○○ 부장이 이 사건 입찰의 최종 계약자를 바꾸기 위하여 공급자증명원 발급을 거절하고 있다고 생각하였으며, 강○○ 부장으로부터 'G사의 요청에 대응하지 말라'는 지시를 받았다고 진술한 바 있다.

<표 13> 2019.1.30. C사 직원(진○○ 이사) 진술조서 발췌

문) MS가 1순위 낙찰자인 G사에게 계약관련 서류를 발급해주지 않은 이유는 무엇이라고 생각하나요? 답) 계약자를 바꾸기 위해서 그랬던 것 같습니다. 서류를 발급해주지 않으면 G사가 탈락할 수밖에 없기 때문입니다. 문) 계약자를 바꾼다는 것은 무슨 의미인가요? 답) MS+★★★ 조합으로 입찰한 G사를 탈락시키고 MS+●● 조합으로 입찰한 차순위 입찰자가 낙찰될 수 있도록 한다는 것입니다. 저는 그런 의도라고 해석했습니다. 문) MS가 계약자를 바꾸려고 한 이유는 무엇이라고 생각하나요? 답) 김△△ 이사나 강○○ 부장이 저에게 직접적으로 말한 적은 없지만, MS+●● 조합으로 가기로 결정되었는데 G사이 사전 협의도 없이 MS+★★★ 조합으로 들어온데다가, 고객인 경북교육청에서도 기존에 쓰던 MS오피스, ●●를 이어서 쓰고 싶어할 것이 분명했기 때문에, G사가 최종 수주하여 계약하는 것이 MS입장에서는 곤란할 것이라고 생각했습니다. 문) (진술인과 G사 김□□ 사장의 녹취록 일부를 보여주며) 진술인은 “총판 영업담당 입장에서는 마이크로소프트에 가이드를 따를 수밖에 없다. 이번 경북건에 대해서는 대응하지 말라는게 가이드다”라고 했습니다. 이때 ‘대응하지 말라’는 것은 누가 한 말인가요? 답) 강○○ 부장에게 들었습니다.

라) G사의 탈락 및 계약자 변경

34 결국 서류제출 마감일인 2017. 10. 30.까지 공급자증명원을 발급받지 못한 G사는 적격심사대상자에서 제외되었으며, 2순위자인 주식회사 J사(이하 ‘J사’)[16]가 피심인의 공급자증명원을 발급 받아 최종 낙찰자로 선정되었다. J사는 이 사건 입찰에서 MS오피스와 ●● 조합으로 소프트웨어 라이선스를 납품하는 내용으로 경상북도교육청과 계약을 체결하였다.

2) 근거

16) J사는 피심인과 A사 제품 모두를 취급하는 대리점으로, 주로 경상북도교육청에 납품해오던 사업자이다.

35 이와 같은 사실은 경상북도교육청 입찰결과(심사보고서 소갑 제4호증[17]), 적격심사대상자 통보(소갑 제5호증), 공급자증명원 발급 요청 내역(소갑 제6호증), 적격심사대상자 제외 통보(소갑 제7호증), J사 공급자증명원 발급 내역(소갑 제8호증), B사 협의내역(소갑 제9호증), 피심인 소명자료(소갑 제10호증), 강○○ 부장 진술조서(2018. 8. 16.)(소갑 제11호증), 김△△ 이사 진술조서(2018. 8. 17.)(소갑 제12호증), 진○○ 이사 진술조서(2019. 1. 30.)(소갑 제13호증), 강○○ 부장 진술조서(2019. 2. 28.)(소갑 제14호증), 강원도교육청 공급자증명원 발급 내역(소갑 제15호증), B사 공급자증명원(소갑 제16호증), 강○○ 부장 메모(소갑 제17호증)등을 통해 인정된다.

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[18]

법 제23조【불공정거래행위의 금지】① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위(이하 '불공정거래행위'라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. 부당하게 거래를 거절하거나 거래의 상대방을 차별하여 취급하는 행위
2. ~ 8. (생략)

② (생략)

③ 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 대통령령으로 정한다.

④~⑥ (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[19]

시행령 제36조【불공정거래행위의 지정】① 법 제23조(불공정거래행위의 금지) 제3항에 따른 불공정거래 행위의 유형 또는 기준은 별표 1의2와 같다.

② (생략)

17) 이하 "심사보고서 소갑 제○호증"은 "소갑 제○호증"으로 기재한다.
18) 2017. 4. 18. 법률 제14813호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.
19) 2017. 9. 29. 대통령령 제28352호로 개정된 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다.

【별표 1의2】 불공정거래행위의 유형 및 기준(제36조 제1항 관련)

1. 거래거절

법 제23조(불공정거래행위의 금지)제1항 제1호 전단에서 "부당하게 거래를 거절하는 행위"라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 행위를 말한다.

가. (생략)

나. 기타의 거래거절

부당하게 특정사업자에 대하여 거래의 개시를 거절하거나 계속적인 거래관계에 있는 특정사업자에 대하여 거래를 중단하거나 거래하는 상품 또는 용역의 수량이나 내용을 현저히 제한하는 행위

2. ~ 10. (생략)

2) 관련 법리

36 거래거절 행위 중 기타의 거래거절 행위에 해당하기 위해서는 ① 특정사업자 또는 특정한 유형의 사업자에 대하여 거래의 개시를 거절하거나, 계속적인 거래관계에 있어서 거래를 중단하거나, 거래하는 상품 또는 용역의 수량이나 내용을 현저히 제한하고, ② 그 거래거절이 부당하여야 한다.

37 기타의 거래거절 행위는 사업자가 단독으로 특정 사업자와의 거래를 거절하는 행위가 대상이 된다. 사업자가 합리적 이유 없이 특정한 유형의 사업자에 대하여 거래를 거절함으로써 거래거절을 당한 사업자가 경쟁상 열위에 처하게 되는 경우에도 거래거절 대상에 해당한다. 다만, 자기의 생산 또는 판매정책상 합리적 기준을 설정하여 그 기준에 맞지 않는 불특정 다수의 사업자와의 거래를 거절하는 행위는 원칙적으로 대상이 되지 않는다.

38 거래거절에는 공급거절과 구입거절, 거래개시의 거절과 거래계속의 거절이 포함된다. 또한 거래상대방에게 현저히 불리한 거래조건을 제시하거나 거래하는 상품·용역의 수량 또는 내용을 현저히 제한하여 사실상 거래를 거절하는 행위도 포함된다.

39 거래거절 행위가 부당한지 여부는 거래거절이 관련 시장에서 경쟁을 제한하는지 여부를 중심으로 판단한다. 경쟁제한성이 있는지 여부는 거래거절 대상이 되는 물품·용역이 거래상대방의 사업영위에 필수적인지 여부, 거래거절을 당한 특정사업자가 대체거래선을 용이하게 찾을 수 있는지 여부, 거래거절로 인해 경쟁사업자의 시장진입이 곤란하게 되는지 여부, 거래거절이 법에 금지된 행위를 강요하기 위한 수단으로 활용되고 있는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

다. 피심인의 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 관련시장의 획정

40 이 사건 입찰을 통해 거래되는 상품은 2018. 3. 1.부터 2019. 2. 28.까지 1년간 경상북도교육청 및 그 산하 기관에서 사용할 업무용 소프트웨어의 라이선스이므로 다른 업무용 소프트웨어 또는 업무용 소프트웨어 라이선스와 대체가능성이 없으며, 거래의 상대방도 경상북도교육청으로 특정되므로 이 사건 거래거절로 인하여 영향을 받는 관련시장은 이 사건 입찰시장에 한정된다고 봄이 타당하다.

2) 거래거절 행위의 존재 여부

41 피심인은 위 2. 가.에서 보는 바와 같이 이 사건 입찰에서 1순위 적격심사대상자로 선정된 G사로부터 해당 입찰에 납품할 MS오피스 소프트웨어 라이선스와 관련된 공급자증명원 발급 요청을 받았으나 이를 거절하였다.

42 G사는 이 사건 입찰 관련 공급자증명원을 발급 받을 경우 적격심사를 통과하여 피심인으로부터 MS오피스 소프트웨어 라이선스를 공급 받아 경상북도교육청에 납품할 수 있었으나[20], 피심인이 공급자증명원 발급을 거절함으로써 G사는 이 사건 입찰에 탈락하여 피심인으로부터 MS오피스 소프트웨어 라이선스를 공급 받을 수 없게 되었다. 따라서 피심인이 G사에 대한 공급자증명원 발급을 거절한 행위는 실질적

20) G사는 B사로부터는 공급자증명원을 발급 받은 상황이었다.

으로 G사와의 MS오피스 소프트웨어 라이선스 공급 관련 거래 개시를 거절한 행위에 해당한다.

3) 거래거절의 부당성 여부

43 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때 피심인의 위 2. 가. 행위는 사업자의 거래 여부에 대한 통상적인 자유의 범위를 벗어나는 행위로서 부당한 것으로 인정된다.

44 첫째, 피심인의 행위는 G사를 이 사건 입찰에 탈락시킬 의도와 목적으로 행하여졌고, 피심인의 행위로 인하여 이 사건 입찰시장에서의 대리점 간 경쟁이 부당하게 제한되었다.

45 앞서 2. 가.에서 살펴본 바와 같이 강○○ 부장은 G사를 이 사건 입찰에 탈락시킬 의도로 G사의 공급자증명원 발급 요청을 거절하였고, 그 결과 G사는 이 사건 입찰에 탈락하여 경상북도교육청이 발주하는 업무용 소프트웨어 라이선스 입찰시장에 진입할 기회를 상실하였다. 특히 각 시·도 교육청이 발주하는 업무용 소프트웨어 라이선스를 취급하는 대리점들 간에 각자의 영업지역을 존중해 주는 관행[21][22]이 있었음을 고려할 때 피심인의 행위는 이러한 대리점들 간 관행을 고착화한 것으로 판단된다.

46 아울러, 피심인의 행위로 인하여 이 사건 입찰의 낙찰자가 변경되었고 결과적으로 경쟁 입찰의 목적인 입찰 참가자 간의 가격 경쟁이 무력화 되었으며, 경상북도교육청은 2순위 사업자인 J사와 계약을 체결함으로써 재정 부담[23]이 가중되었

21) “공정거래위원회 제1소회의 의결 제2020-216호(2020. 8. 12.)”에서 인정된 사실에 비추어 볼 때, 각 시·도 교육청에 업무용 소프트웨어 라이선스를 납품하는 각 대리점들 간에는 본인의 영업지역 외의 지역은 낙찰되어도 사후관리 비용 부담이 커서 이득이 크지 않은 반면, 각 대리점 영업지역별로 낙찰 받는 분위기가 유지되면 안정적인 이윤 획득이 가능하기 때문에 각자의 연고지역을 존중해 주는 관행이 있었다.

22) 이러한 관행에 따라 각 시·도에 위치한 12개 대리점들은 각 시·도 교육청이 발주하는 교육기관 업무용 소프트웨어 라이선스 구매 입찰 시장에서 발주처가 소재한 지역을 영업지역으로 하는 대리점을 낙찰 예정자로 정하기로 합의하였고, 16건의 입찰에서 이를 실행하였다[공정거래위원회 제1소회의 의결 제2020-216호(2020. 8. 12.)].

다.[24]

47 둘째, G사는 피심인 외에는 대체거래선이 존재하지 않았으므로 피심인의 행위가 이 사건 입찰 시장에서의 경쟁제한 효과 발생의 직접적인 원인이 되었다.

48 G사는 당초 A사의 공인파트너사가 아니었으며, A사는 2007년 공인파트너 대리점 제도를 도입한 이후부터 이 사건 입찰 때까지 공인파트너 대리점이 아닌 대리점에게 공급자증명원을 발급한 사례가 없으므로[25], G사가 이 사건 입찰 공고 시부터 적격심사 서류제출 마감일까지 A사의 공인파트너사가 되어 공급자증명원을 발급 받는 것은 현실적으로 불가능하였을 것으로 판단된다.[26]

49 아울러, 공급자증명원은 경상북도교육청에게 G사가 피심인의 공인파트너임을 확인시켜 주는 문서에 불과한데[27], G사는 피심인의 공인파트너에 해당하므로 G사가 피심인으로부터 공급자증명원을 발급 받지 못할 상황을 예견하기도 어렵다.

50 셋째, 피심인의 공급자증명원 발급거부 행위에 합리적 사유가 있다고 보기 어렵다.

51 G사는 2010년부터 피심인의 공인파트너사로서 강원도교육청 등 다른 교육청에 여러 차례 납품한 실적이 있는 사업자이므로 이 사건 입찰 관련 제품 납품이 어렵다고 볼만한 사유가 존재하지 않는다.

52 이와 관련하여 피심인은 G사의 공급자증명원 발급 요청서에 납품할 제품의

---

23) G사와 J사의 투찰금액 차액인 약 213,100천 원이 이에 해당한다.
24) 이 사건 입찰에서 대리점들 간 경쟁이 제한되고 수요기관의 부담이 증가한 것은 낙찰자인 J사와 탈락자인 주식회사 G사 간의 담합행위[공정거래위원회 제1소회의 의결 제2020-217호(2020. 8. 12.)]로 인하여 발생된 측면도 있으나, 피심인의 행위가 없었다면 담합 내용과는 다르게 G사가 낙찰자가 되었을 것이므로 피심인의 행위로 담합에 따른 대리점들 간 경쟁제한 효과가 가중되었다는 점은 분명하다.
25) 이 사건 입찰 관련 담합 사건(2017입담3085)의 피심인인 A사가 의견서를 통해 진술한 내용이다.
26) 이 사건 입찰 관련 담합 사건(2017입담3085)에 대해 A사가 제출한 의견서에 의할 때, A사는 대리점의 과거 자사 제품 납품 실적 등을 평가하여 신규 공인파트너를 선정하고 있는 것으로 확인되므로 A사와의 거래관계가 없는 G사가 단기간에 A사의 신규 공인파트너 대리점이 되는 것은 현실적으로 어렵다.
27) 경상북도교육청 입찰 규격서(소갑 제3호증)에는 “계약 시 제조사의 공인인증파트너를 증명할 수 있는 인증서 및 공급증명원을 제출한다.”라고 기대되어 있다.

상세내역 및 수량 등이 명확하게 기재되지 않아 공급자증명원 발급이 어려웠다고 주장하나, 경상북도교육청의 입찰규격서 만으로도 제품의 상세명은 특정되는 점, 제품 수량 또한 2017. 10. 26. G사가 적시하여 재차 피심인에게 발급 요청서를 보낸 점, G사가 수차례 피심인 측에 공급자증명원 발급과 관련하여 연락을 취한 점, 강○○ 부장 또한 스스로 공급자증명원 발급 거부 행위가 위법 소지가 있는 지 자체적으로 검토하였던 점 등을 고려할 때 이러한 피심인의 주장은 이유 없다.

4) 소결

53 피심인의 위 2. 가. 행위는 법 제23조 제1항 제1호, 법 시행령 제36조 제1항 [별표 1의2] 1. 나목의 행위에 해당하므로 위법하다.

3. 처분

54 피심인이 앞으로 위 2. 가.의 행위와 동일하거나 유사한 법 위반행위를 하지 않도록 하기 위하여 피심인에게 시정명령을 부과한다.

4. 결론

55 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제23조 제1항 제1호의 규정에 위반되므로, 법 제24조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2020년 8월 24일

의 장 위 원 신 영 호

위 원 김 형 배

위 원 정 재 훈